



Número: **5026724-11.2025.8.08.0024**

Classe: **MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL**

Órgão julgador: **Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho**

Última distribuição : **14/07/2025**

Valor da causa: **R\$ 1.000,00**

Assuntos: **ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
RODRIGO ALVES COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
LUIZ ROBERTO COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
EDNA ALVES DOS SANTOS COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (COATOR)			
ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IMPETRADO)			
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CUSTOS LEGIS)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
72987271	14/07/2025 23:43	Petição Inicial	Petição Inicial

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA DA FAZENDA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO - COMARCA DA CAPITAL

CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO, brasileira, médica, divorciada, portadora do CPF nº 111.768.167-05, residente e domiciliada à Avenida Rio Branco, 1384, Apto n. 402, Bairro Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-642, **RODRIGO ALVES COGO**, brasileiro, casado em regime de comunhão de bens, empresário, nascido em 28 de janeiro de 1987, portador do CPF n. 117.121.317-45, com endereço comercial à Rua João da Cruz, n. 25, Sala 401, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-620, **LUIZ ROBERTO COGO**, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13 de janeiro de 1956, portador do CPF n. 809.749.108-72 e da Carteira de Identidade n. 5.086.719 SSP-SP, residente e domiciliado à Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 254, Apto 501, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.057-630, **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO**, brasileira, empresária, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 22 de julho de 1959, portadora do CPF n. 032.774.148-17 e da Carteira de Identidade n. 9.498.278 SSP-SP, residente e domiciliada a Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 254, Apto 501, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.057-630; comparecem respeitosamente perante V. Exa., por seu procurador que esta subscreve, para impetrar o presente

**MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO**

Em face do **SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. João Batista Parra, 600 - Enseada Do Suá, CEP: 29.050- 375 - Vitória/ES, representada judicialmente pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO localizada na Av. Nossa Sra. da Penha, 1590 - Barro Vermelho, Vitória - ES, 29057-550, notadamente em razão da iminente cobrança ilegal de ITCMD frente a doação recebida pela Impetrante, ilegalidade essa em razão da **revogação automática - pela não recepção** - dos artigos 10, 12 e 13 da Lei Estadual 10.011 de 2013 pela incompatibilidade com a Emenda Constitucional n. 132 de 2023, vigente a partir de 21 de Dezembro de 2023, conforme se passa a detalhar.



DOS FATOS

Os Impetrantes são sócios das empresas **COGO PARTICIPAÇÕES Ltda.** e **COGO PATRIMONIAL Ltda.**, ambas devidamente registradas na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e de CNPJs 58.355.568/0001-05 e 58.355.485/0001-16. Em Julho de 2025, os autores CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO e RODRIGO ALVES COGO **receberam por cessão não onerosa** adicionais cotas empresariais de ambos CNPJs advindas dos outros dois impetrantes. Cada um dos donatários recebeu as seguintes transmissões:

Empresa	# de Cotas Recebidas	Valor da Doação
Cogo Patrimonial (58.355.485/0001-16)	456.260	R\$ 456.260,00
Cogo Participações (58.355.568/0001-05)	1.058.835	R\$ 1.058.835,00

A *quaestio* em voga está ao redor da **atual e completa inexistência de legislação estadual que estipule uma alíquota ou base de cálculo de ITCMD válida**. Mas acaso perdurasse a outrora validade do imposto de doação (*antes de Jan/2024*), a operação em tela somaria R\$ 1.515.095 (*um milhão, quinhentos e quinze mil, noventa e cinco reais*) em patrimônio recebido por doação (*base de cálculo*) por donatário, o que resultaria num valor de 4% de ITCMD na soma de R\$ 60.603.80 (*sessenta mil, seiscentos e três reais e oitenta centavos*) para cada beneficiário. Essa **era** a sistemática anterior, ora inexistente e “inconstitucional”¹.

A Lei Estadual n. 10.011 de 2013 regulamenta o ITCMD no Estado do Espírito Santo. E considerando que nem toda lei foi extirpada, mas apenas os artigos que agora estão incompatíveis com o Texto Maior, a demandante protocolou junto à Secretaria de Fazenda Estadual a notificação quanto à doação ainda dentro de 30 dias da mesma, tal qual como determina a Lei. As guias foram registradas sob os n. 20250000011982, 20250000011988 e 20250000011989 (**doc. anexo**), protocoladas em 10/Julho/2025 e que, em breve, poderão ser exigidas contra os Impetrantes.

No entanto, como se verá abaixo, não há alíquota de ITCMD válida e vigente desde 21 de Dezembro de 2023, o que retira da SEFAZ o direito/dever de exação tributária vide a ausência de lei que valide e/ou anteceda à cobrança (art. 150 CF).

¹ Entre aspas porquê, como veremos, o instituto correto a ser tratado é o da não-recepção. Mas para fins iniciais, o termo “inconstitucional” traz o mesmo sentido, de que a norma foi / está extirpada do ordenamento jurídico.



Por outro lado, o Estado do Espírito Santo não suspendeu a cobrança do ITCMD, apesar da clara violação ao direito líquido e certo. Compulsando o **Portal da Transparência do Poder Executivo do ES** (vide **doc. anexo**), vê-se que no último mês de Junho de 2025, o Estado arrecadou R\$ 16.673.842,34 de ITCMD, quedando-se evidente que não há suspensão de cobrança mesmo diante de patente ilegalidade e inexistência do normativo estadual.

E aqui se verifica o caráter preventivo desse *mandamus*. Considerando que a autora está na espera da resposta da Sefaz quanto ao ITCMD sobre cessão não onerosa da qual foi beneficiária, e, considerando, ainda, a clara ilegalidade da cobrança e o fato de o Estado não ter paralizado as cobranças do ITCMD, nem a negativação ou inscrição em dívida ativa pelo não pagamento, entende-se ser o *Mandado de Segurança Preventivo* o caminho para garantir o direito em tela.

DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

O cerne deste *writ* é a **inexistência de norma, a partir de 21 de Dezembro de 2023, que estipule alíquota de ITCMD no Estado do Espírito Santo**. Apesar desta questão em relação ao ITCMD no ES ser nova e *ainda não enfrentada no TJ/ES ou pelas cortes superiores*, o arcabouço jurídico que legitima essa demanda não é novidade: imediata não recepção de leis infraconstitucionais após alteração constitucional via Emenda Constitucional. **Precedentes STF.**

No caso, a Emenda Constitucional n. 132 de 2023, com vigência a partir de 21/12/2023, não recepcionou os artigos 10, 12 e 13 da Lei Estadual 10.011 de 2013 (*lei que institui o ITCMD no Espírito Santo*), sendo esses os artigos que definem a alíquota fixa de 4% de ITCMD no Espírito Santo sob o valor total do direito transmitido e/ou doado.

Em um breve resumo histórico-jurídico do direito líquido e certo em tela, tem-se que desde a Resolução n. 9 de 1992 do Senado Federal (*autorizado pela CF/88*) e até a EC 132, os Estados poderiam adotar **ou alíquota fixa ou, facultativamente, progressiva de ITCMD**.

A edição da **EC 132/2023**, entretanto, trouxe à CF a **obrigatoriedade da alíquota progressiva** e a necessidade de se aplicar a progressividade sobre o quinhão ou cota-parte doada, e não sobre o valor total do direito herdado ou doado (*herança global*).

Essa mudança da CF torna a legislação do ES materialmente incompatível com a Constituição. É o presente caso: o artigo 12 da Lei Estadual que institui o ITCMD estipula uma alíquota fixa de 4%



ao invés de progressiva, e mesmo passados 18 meses da alteração Constitucional, o Ente Federado se manteve inerte. Dezenas são os julgados do STF no sentido de reconhecer a revogação imediata pela não recepção de leis infraconstitucionais após Emenda Constitucional, o que será visto em capítulo próprio.

São vários os elementos de direito que permeiam a questão, e essa exordial tem o objetivo de abordar diversos potenciais caminhos de discussão, ora resumida nos seguintes tópicos:

1. Questões Processuais

- a. Do Cabimento e da Legitimidade Ativa no *mandamus* preventivo
- b. Legitimidade Passiva / Autoridade Coatora

2. Questões de Direito Material

- a. Como era até 21/12/23: *Determinação Constitucional Originária e Lei Estadual*
- b. Mudança a partir de 21/12/23: *Emenda Constitucional 132/2023 e seus efeitos*

i. Diante dessa nova Ordem Constitucional, **nascem duas perguntas de direito:**

- 1. A alíquota é de fato obrigatoriamente progressiva ou uma faculdade aos Estados?
- 2. Entendendo que é obrigatoriamente progressiva, a partir de quando produz efeito?

1. *Ratio legis*: **A alíquota é de fato obrigatoriamente progressiva?**

- 3. Interpretação Gramatical
- 4. Interpretação Teleológica (*discussão do conceito de "será progressivo" pelos Legisladores Constituintes Derivados*)
- 5. Interpretação pela Tipicidade Cerrada de Conceito Tributário
- 6. Interpretação Sistemática - que conduz à revogação imediata

2. Da **não-recepção Constitucional** e da **Revogação Imediata (STF)**

- 7. Posição do STF sobre a não recepção de leis após EC
- 8. Interpretação do STF sobre o predicado "será" vs. "poderá" em caráter tributário
- 9. Revogação Por Assimilação: Novo Inciso da CF regula toda a matéria
- 10. Revogação Tácita: incompatibilidade da norma infraconstitucional com a CF

ii. **Efeito:** Inexistência de legislação que define a alíquota do ITCMD no ES (Art. 150, CF)

iii. Do Erro e da Impossibilidade do Consequencialismo Econômico Judicial

iv. Do Pedido Liminar

v. Dos Pedidos



QUESTÕES DE DIREITO PROCESSUAL

DO CABIMENTO E DA LEGITIMIDADE ATIVA

Do MS Preventivo e da Sujeição Passiva do ITCMD

A Constituição Federal preconiza no art. 5º, LXIX que "*conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público*".

A Lei 12.016/2009 é clara ao prever que o Mandado de Segurança objetiva proteger direito líquido e certo sempre que houver (*ou estiver para acontecer*) a prática de ato lesivo ou abuso de poder pela autoridade pública, estando consolidado o entendimento, tanto na doutrina como na jurisprudência, de que a via do *mandamus* pode ser utilizada preventivamente, a fim de prevenir ou evitar lesão ou dano diante de ameaça concreta ou justo receio:

Hely Lopes Meireles: "*O mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa pôr em risco o direito do postulante. O mandado de segurança preventivo tem sido muito utilizado em matéria tributária, em especial para proteção contra a cobrança de tributos inconstitucionais*"²

Hugo de Brito Machado: "Em matéria tributária merece o Mandado de Segurança preventivo especial atenção, pois a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. [...] Em síntese e em geral, o mandado de segurança é preventivo quando, já existente ou em vias de surgimento a situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal, tal ato ainda não tenha sido praticado, existindo apenas o justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade impetrada É preventivo porque destinado a evitar a lesão ao direito, já existente ou em vias de surgimento, mas pressupõe a existência da situação concreta na qual o impetrante afirma residir ou dela decorrer o seu direito cuja proteção, contra a ameaça de lesão, está a reclamar do Judiciário."³

O STJ é uníssono em aceitar o Mandado de Segurança Preventivo na esfera tributária, aduzindo, ainda, que o *writ* é cabível para evitar que a autoridade coatora proceda ao lançamento fiscal ilegal, uma vez que, à luz do art. 142, CTN, o lançamento tributário é atividade administrativa vinculada e obrigatória:

² MEIRELES, Hely Lopes, "MANDADO DE SEGURANÇA", Malheiros, 31ª Ed., 2008, p. 25.

³ Machado, Hugo de Brito, "Mandado de Segurança em Matéria Tributária". 3a ed.; São Paulo: Dialética, 1998, p. 222/255/257



Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. **A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.**

STJ: EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.169.402 - SP (2017/0230136-2)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ISS SOBRE ATIVIDADES EXERCIDAS POR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS. ACÓRDÃO EMBARGADO FIRMADO COM BASE EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO PARA AFASTAR O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DO WRIT OF MANDAMUS NA MODALIDADE PREVENTIVA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE LANÇAMENTOS FISCAIS REGULARMENTE INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, A FIM DE PROVER O RECURSO ESPECIAL, PARA, RECONHECENDO O CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIÇÃO DAS QUESTÕES REMANESCENTES.

Outros Precedentes no STJ: AgInt no REsp. 1.270.600/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 13.6.2018; AgRg no AREsp. 543.226/PE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.12.2015; AgRg no Ag 1.302.289/RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 8.11.2010; REsp. 860.538/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16.10.2008.

No caso dos autos, o *writ* se justifica na medida em que a Contribuinte objetiva evitar que atos abusivos de cobrança venham ocorrer, haja vista que o Estado do ES não suspendeu as cobranças de ITCMD desde a revogação da lei estadual pela não recepção e, pelo contrário, o estado acredita estar obrigado - por força do art. 142, CTN, a proceder com as cobranças de 4% sobre o valor da doação para fins de ITCMD.

Como visto acima, no mês de Junho de 2025, o Estado arrecadou R\$ 16.673.842,34 de ITCMD, quedando-se evidente que não há suspensão de cobrança mesmo diante de patente ilegalidade e inexistência do normativo estadual.

Destaca-se, ainda, que - como será visto em tópico próprio abaixo, a **revogação de lei infraconstitucional por não recepção é ato imediato assim que vigente o normativo constitucional (original ou derivado), conforme precedentes do STF, não** sendo condicionada à um ato complementar ou enunciação judiciosa futura que, apenas a partir daí, revogue a lei inconstitucional / não recepcionada.



Não se trata, pois, de matéria em tese, mas concreta ausência de constitucionalidade na cobrança de tributos sem prévia lei que a estabeleça (art. 150, CF), fato que opera efeitos diários na cobrança indevida de ITCMD no Espírito Santo.

No que pertine à **legitimidade ativa** do Mandado de Segurança, traz-se à baila o art. 8º da Lei Estadual n. 10.011/2013, que define os sujeitos passivos da obrigação tributária para doações no estado do Espírito Santo:

Art. 8.º São contribuintes do imposto:

I - o herdeiro ou o legatário, na transmissão causa mortis;

II - o donatário, na doação;

III - o doador, caso o donatário não residir nem for domiciliado neste Estado;

Adicionalmente, o art. 9º do mesmo diploma Estadual expande a responsabilidade tributária aos doadores (*inciso I*), excluindo-se, ainda, o benefício de ordem, o que torna os doadores possíveis responsáveis de imediato e, portanto, legítimos para também compor o polo ativo desta demanda.

Art. 9.º São solidariamente responsáveis pelo imposto devido:

I - o doador, o cedente ou o donatário, quando não contribuintes;

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA

É inquestionável que a autoridade coatora é de âmbito Estadual, haja vista a competência dos Estados, conforme art. 155, I da CF, em instituir - e cobrar - o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD.

A discussão passa a ser, portanto, **quem seria a autoridade coatora dentro da estrutura de governo?** Governador? Secretário da Fazenda? Subsecretário? Agente Fiscal?

No caso presente, e sobremaneira em se tratando de um Mandado de Segurança Preventivo (*buscando evitar um ato futuro*), **entendemos ser o Subsecretário de Estado de Receita a autoridade coatora e polo passivo legítimo desse mandamus preventivo**, vez que é o responsável direto pela supervisão, orientação e controle do sistema de tributação, fiscalização e arrecadação, conforme Lei Complementar Estadual n. 225 de 2002 do Espírito Santo, que em seu artigo 6º, detalha as atribuições do subsecretário como:



Art. 6º A Subsecretaria de Estado da Receita - **tem como jurisdição administrativa o planejamento, a supervisão, orientação, controle e avaliação das atividades relacionadas com a administração do sistema de tributação, fiscalização, arrecadação e de dados econômico-fiscais da Secretaria**, no âmbito central e regional; a recomendação de medidas necessárias ao **bom funcionamento da fiscalização tributária, a fim de assegurar a plena consecução de seus fins; a aprovação, nos limites de sua competência, de matérias afetas à área tributária e fiscal**; o assessoramento ao Secretário na sua área de competência; a representação do Secretário de Estado da SEFAZ nos órgãos colegiados, quando por ele designado; a substituição do Secretário de Estado da Fazenda nos seus impedimentos nos assuntos de sua área de competência; o desenvolvimento de outras tarefas compatíveis com a função, determinadas pelo Secretário da SEFAZ.

Outrossim, a Lei do Mandado de Segurança, n. 12.016/2009, prescreve em seu art. 6, § 3º que **a autoridade coatora** é aquela que praticou o ato impugnado ou **detém competência para desfazê-lo.**

No caso de Mandado de Segurança **Preventivo**, deve-se entender como autoridade coatora **aquela que praticará ou aquela que detém a competência para desfazer o ato que será, num futuro próximo, praticado.**

Numa primeira leitura, poder-se-ia assumir ser o Secretário da Fazenda ou até mesmo o Governador a autoridade com poderes para desfazer o ato praticado. No entanto, o STJ tem afastado, via de regra, a legitimidade passiva do Governador e do Secretário de Estado. Em inúmeros julgamentos, a Corte Superior estampou a tese de que **Governador e Secretário da Fazenda não lançam tributos**, não podendo, portanto, figurarem como polo passivo de MS como autoridade coatora.

Vide RMS 42.792:

"Tais atividades, por determinação legal, são atribuídas a outras autoridades fiscais, de escalão hierárquico subalterno. **Assim, na hipótese, inexiste ato que possa ser atribuído ao governador do estado ou ao secretário de Fazenda**", explicou o relator do processo, ministro Mauro Campbell Marques.

No mesmo sentido: RMS 37.270/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.4.2013, RMS 30.512/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 26.9.2011, RMS 31.648/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10.3.2011, AgRg no RMS 33.189/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 24.2.2011, RMS 32.342/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 2.2.2011 e AgRg no Ag 1.302.289/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 8.11.2010.

Todos os precedentes, apesar de possuírem mais de 10 anos da data do julgamento, ainda representam a visão atual do STJ e são mencionados como jurisprudência pacificada em todos os recentes casos.



No TJ/ES, estado ora em tela, também existe um **entendimento unânime** de que o **Secretário da Fazenda não pode ser apontado como autoridade coatora**, como se vê resumido na seleção de dois recentes julgados:

TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 50132727420238080000 Jurisprudência Acórdão publicado em **14/08/2024** Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL QUE IMPORTA EM ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1 – O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o **“Secretário da Fazenda Estadual não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que trata de questões envolvendo tributos”** (STJ, AgInt no RMS n. 68.977/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). 2 - A jurisprudência tem se manifestado pela impossibilidade de emenda à petição inicial do Mandado de Segurança quando esta importar em mudança de competência. 3 – Considerando que o Secretário de Estado da Fazenda não detém legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora no Mandado de Segurança em que se discute a concessão de benefício fiscal, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e da impossibilidade de emenda à petição inicial por importar em mudança de competência. 4 - Segurança denegada.

TJ-ES - Mandado de Segurança Cível 50018556120228080000 Jurisprudência Acórdão publicado em **04/10/2022** Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 5001855-61.2022.8.08.0000 EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO ORIGINÁRIO – TRIBUTÁRIO – ICMS-DIFAL – ANTERIORIDADE – AUTORIDADE COATORA – SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO NÃO APLICÁVEL – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Como cedido, a via processual em testilha tem como função “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade” (artigo 1º da Lei nº 12.016 /2009). 2. **Entende-se como autoridade coatora aquela que pratica ou praticará, no caso de mandado de segurança preventivo, o ato impugnado.** 3. **O Secretário de Estado da Fazenda não tem legitimidade para figurar como autoridade coatora, isso porque a autoridade responsável pelos atos alegados na peça inicial é o Auditor Fiscal da Receita Estadual ou o Subsecretário de Estado da Receita.** 4. Não sendo o suposto ato ilegal de competência do Secretário de Estado, mas por autoridade diversa da indicada, resta caracterizado o desatendimento à disposição expressa do artigo 6º, da Lei nº 12.016 /09. 5. O Superior Tribunal de Justiça, assim já decidiu: “pretensão relacionada à emissão de ordem para impedir a fiscalização e cobrança do ICMS que deve ser dirigida ao Agente Fiscal que detém atribuição para a prática do ato, e não ao Governador do Estado ou ao Secretário de Estado da Fazenda”. (AgInt no RMS 56.103/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018) 6. Em que pese a impetrante tenha apontado como autoridade coatora aquela hierarquicamente superior à responsável pela prática direta do ato, é vedada a aplicação da Teoria da Encampação na hipótese vertente, sob pena de se modificar e ampliar indevidamente a competência originária deste e. Tribunal de Justiça. Precedentes. 7. Mandamus extinto sem resolução do mérito.

Os poucos casos em que o Secretário de Estado é admitido como autoridade coatora são aqueles em que o Chefe da Pasta **pessoalmente** produziu / assinou / emitiu o ato atacado, como no exemplo abaixo também do TJ/ES:



TJ-ES - Mandado de Segurança: MS 11601320138080000 Jurisprudência Acórdão publicado em 20/08/2013
Ementa: EMENTA : MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - CABIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA - RECUSA A CERTIFICADOS DE CURSOS LIVRES NÃO CREDENCIADOS - RECUSA LEGÍTIMA E PREVISTA NO EDITAL - SEGURANÇA DENEGADA. 1- É possível a impetração de mandado de segurança preventivo quando já existente situação de fato que ensejaria a prática de ato considerado ilegal, ainda que tal ato não tenha sido praticado, existindo apenas o justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade coatora. Preliminar rejeitada. 2- **Autoridade coatora é aquela que tem poderes para desfazer o ato impugnado, ainda que não o tenha praticado. Verifico que as normas do edital do processo seletivo simplificado foi determinado pelo Secretário de Estado da Educação, portanto, tenho como satisfeita uma das condições de ação, qual seja, a legitimidade passiva, analisada in statu assertionis** . Preliminar rejeitada. 3- Os certificados apresentados possuem um carimbo do ISECUB (Instituto Superior de Educação e Cultura Ulysses Boyde), que registra convênio com o Centro Educacional Adevalni Azevedo, o que seria ilegal, eis que os termos da alínea 2.º, da resolução 1.985/2009, do Conselho Estadual de Educação, proíbe que os cursos livres sirvam-se de convênios com instituições integrantes de qualquer sistema de ensino para validade dos cursos livres. 4- O requisito impugnado do edital passou a constar dos editais de processo simplificado em razão da existência de inúmeras denúncias de irregularidades na expedição dos certificados emitidos pelo Centro Educacional Adevalni Azevedo. 5- Os critérios para análise da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo devem ser aferidos diante de situações concretas, cabendo ao Poder Judiciário, desde que provocado, apreciar as restrições impostas pela administração pública, e que, no presente caso, se mostraram adequadas, necessárias e justificadas pelo interesse público. 6- Segurança denegada.

TJ-ES - Mandado de Segurança: MS 223119320178080000 Jurisprudência Acórdão publicado em 19/04/2018
Ementa: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. § 3º DO ART. 6º DA LEI Nº 12.016 /2009. PRELIMINAR REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA DO ATO LESIVO. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. UTILIZAÇÃO DE EMPECILHO ADMINISTRATIVO COMO MEIO DE COBRANÇA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ILEGALIDADE. SÚMULAS E JURISPRUDÊNCIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE DEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . 1. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Autoridade Coatora 1.1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, a teor do disposto no § 3º do art. 6º da Lei nº 12.016 /2009. 1.2. Com isso, **parece-me inviável afirmar que o Secretário de Estado não poderia integrar o polo passivo do mandamus**, haja vista ser plausível o entendimento de que é dotado de poderes para desfazer o ato tido por ilegal, ou seja, autorizar a emissão das notas fiscais eletrônicas conforme pretendido pela impetrante. 1.3. Preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora rejeitada. 2. Da preliminar de Inadequação da Via Eleita 2.1. Insurgindo-se contra o ato que suspendeu/bloqueou a emissão de notas fiscais eletrônicas, a impetrante bem instruiu o seu mandado de segurança com a prova do ato lesivo ao direito alegado. 2.2. Aliás, a suspensão/bloqueio de notas fiscais pela Fazenda nem é fato controvertido nesta demanda, uma vez que nas informações, tanto a autoridade coatora quanto a pessoa jurídica de direito público, não só confessam como defendem a legalidade do ato combatido.

Na presente querela, não houve nem haverá ato pessoalmente produzido ou a ser produzido pelo Secretário da Fazenda, mas sim pelo Subsecretário de Estado da Receita - conforme art. 6º da Lei Estadual n. 225 de 2002, acima transcrito.

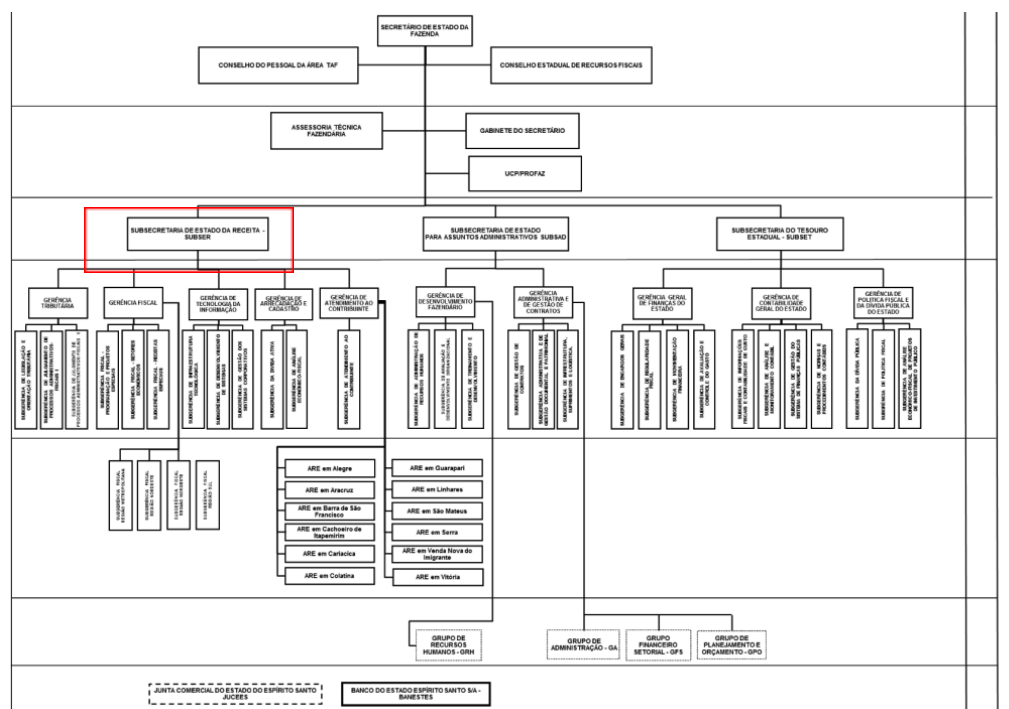


Para fins de baliza de entendimento jurisprudencial desse TJES, nos valem do mais recente julgado sobre o tema, **datado de Outubro de 2024**, onde se reiterou que o Subsecretário de Estado da Receita é o agente coator correto para figurar no polo passivo de MS:

TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 50017455320238080024 Jurisprudência **Acórdão publicado em 25/10/2024** Ementa: Ementa: DIREITO PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE TARIFAS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TUSD E TUST. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA contra ato supostamente praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo, visando à exclusão das tarifas TUSD, TUST e Encargos Setoriais da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, alegando violação ao Princípio da Legalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Estado da Fazenda possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança; (ii) verificar a possibilidade de exclusão das tarifas TUSD, TUST e Encargos Setoriais da base de cálculo do ICMS. III. **RAZÕES DE DECIDIR** 3. **Conforme o art. 6º, § 3º, da Lei n.º 12.016 /2009, a autoridade coatora é aquela que praticou o ato impugnado ou detém competência para desfazê-lo, sendo o Subsecretário de Estado da Receita o responsável pelos atos relacionados à administração tributária, conforme previsto na Lei Complementar Estadual 225/2002.** 4. **Precedentes do STJ e do TJES indicam que o Secretário de Estado da Fazenda não detém legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança que questionam a cobrança de tributos, visto que suas funções são de caráter estratégico e não operacional.** 5. A aplicação da teoria da encampação, que permitiria a manutenção do Secretário no polo passivo, é inaplicável, pois resultaria na ampliação indevida da competência jurisdicional deste Tribunal, em desacordo com a Súmula 628 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. **O Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança relacionado à administração de tributos.** 2. A teoria da encampação é inaplicável quando sua aplicação resulta na modificação da competência jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97, IV; CPC/2015, art. 485, VI; Lei n.º 12.016 /2009, art. 6º, § 3º; Lei Complementar Estadual n.º 225/2002, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 71.987/SC, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25/09/2023, DJe 28/09/2023; STJ, RMS n. 68.200/RJ, rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15/02/2022, DJe 15/03/2022; TJES, MS Cível 5001752-45.2023.8.08.0024, rel. Samuel Meira Brasil Junior, j. 24/05/2024.

Não há enredo *ad causam* que justifique o apontamento de outra autoridade executora, como Gerente Tributário, Fiscal ou Regional Fazendário. O ato é futuro (*iminente*) e não há um agente único vinculado à futura execução desse ato, senão o Subsecretário, responsável por todas as gerências da pasta, e a única pessoa que poderia desfazer o ato ora questionado.





Doc. anexado para melhor redação

Por fim, e para não deixar dúvida sobre o tema, mister se faz colacionar o artigo 9 da Lei Estadual 3.043 de 1975, ainda vigente, que definiu a estrutura organizacional do Estado do Espírito Santo.

Art. 9º - A estrutura organizacional básica de cada uma das Secretarias de Estado, atendidas as suas peculiaridades, pode compreender unidades administrativas dos seguintes tipos e níveis:

III - Nível de Gerência, representado pelo Subsecretário de Estado com funções relativas à implantação e controle de programas e projetos, bem como à ordenação das atividades de gerência, concernente aos meios administrativos necessários ao funcionamento regular da Pasta;

Ad argumentandum tantum, caso V. Exa entenda que a autoridade coatora seja alguns dos Gerentes ou Subgerentes Fazendários, ou ainda algum agente futuro e indefinido (?), que seja aplicada a Teoria da Encampação disposta na Súmula 628 do STJ, que assim versa:

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (SÚMULA 628, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)



Desta feita, e considerando que a jurisprudência do STJ é pacífica ao afastar a legitimidade passiva do Governador ou do Secretário de Estado para responderem MS (*preventivo ou não*) sobre questões de administração tributária, e ainda considerando o reiterado entendimento de tal legitimidade caber ao Subsecretário, é que se aponta e requer o deferimento do Subsecretário da de Estado da Receita como autoridade coatora desse *writ*. Subsidiariamente, caso V. Exa. entenda que a competência caberia à algum Gerente ou Subgerente da Pasta, que seja aplicada a Teoria da Encampação para permitir a extensão do polo passivo sem a extinção da demanda.

QUESTÕES DE DIREITO MATERIAL LÍQUIDO E CERTO

Abaixo, veremos a seguinte cronologia de argumentos jurídicos baseados em alterações legislativas com efeitos práticos na vida dos contribuintes e jurisdicionados.

O que apregoava a CF sobre alíquota de ITCMD entre 1988 e 21/Dez/2023

1. A CF/88 define em seu art. 155, I a competência dos Estados para instituição e cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação. **O texto original da CF era silente sobre eventual progressividade**, nem permitindo nem proibindo, como **também não detalhava a base de cálculo**; se sobre o valor total herdado/doado ou se do quinhão/cota-parte da transmissão;
2. A CF defere ao Senado a estipulação da alíquota máxima de ITCMD. A Resolução do Senado n. 9 de 1992 é a mais recente sobre o tema, definindo a alíquota máxima do ITCMD em 8%, e **facultando a progressividade - frente ao silêncio da CF sobre o tema. No mesmo sentido, Súmula 21 do STF**;

Como os Estados respeitavam a CF no modelo anterior (*hoje, obsoleto*)

3. Os Estados, por sua vez, possuem as suas legislações locais de ITCMD, sendo variada a escolha entre os Entes Federados, alguns definindo pela alíquota fixa e outros a progressiva, há décadas. No Espírito Santo, a Lei 10.011, publicada em 2013, revogou a legislação anterior Lei n.º 4.215, de 1989, e estipula o ITCMD no Estado;
4. O artigo 12 da Lei Estadual de 2013 define uma **alíquota fixa de 4%**, adotando, ainda, a **base de cálculo como o valor total da herança ou doação**, como se vê no artigo 10. O artigo 13, por sua vez, detalha a operação matemática para aplicar os 4% sobre o volume total herdado ou doado, e não cota-partes;



O que mudou em 21/Dez/2023 com a EC 132: Base para a revogação da Lei Estadual

5. A dinâmica jurídica acima descrita estava perfeita e constitucional **até** a edição da Emenda Constitucional n. 132/2023, publicada dia 21/Dez/2023 e vigente, no quesito ITCMD, **de imediato**;
6. Na EC 132/23, decidiu o Legislador Constituinte Derivado **se posicionar e definir pela obrigatória progressividade** do ITCMD, pelo que acrescentou um novo inciso (VI) ao artigo 155, par. 1º da CF para tal monta, alterando, ainda, a base de cálculo agora lastreada apenas no quinhão ou cota-parte da doação, suprimindo a lacuna que permitia legislações com base na herança global;
7. O que antes era facultativo aos Estados, deixou de ser por uma **escolha** do predicado verbo-nominal "será" progressivo. Nas razões de direito abaixo, vamos debruçar sobre o entendimento quanto à obrigatoriedade ou não do "será progressivo" e, partindo-se da conclusão de que o "será" é uma obrigação, entraremos no estudo sobre o início do efeito e da eficácia (se imediata ou não) da mudança Constitucional;
 - a. Possui o estado o prazo que quiser para se ajustar? Possui, na verdade, algum prazo?
8. Antecipando-se à conclusão pelo efeito obrigatório e imediato do "será progressivo", tem-se que após a alteração da CF via EC n. 132/2023, toda legislação infraconstitucional que fere a obrigatória progressividade do ITCMD e o formato da base de cálculo definidos pela nova CF está, de plano, extirpada do Sistema Jurídico, ou "inconstitucional" *numa maneira simplória e atécnica de apontar a questão sub judice*;

Conclusão: Revogação Imediata das Leis Infraconstitucionais Após EC 132/23

9. O STF não admite a teoria da "inconstitucionalidade superveniente", por outro lado, a Corte Suprema é pacífica ao aplicar a **Teoria da Não Recepção Imediata**, entendendo que toda legislação infraconstitucional que fere a CF (*seja pelo constituinte originário ou derivado*) está **automaticamente e imediatamente revogada e expurgada do mundo jurídico**;
 - a. **Diversos julgados do STF nesse sentido, sendo essa a questão principal desse writ**
10. No caso concreto, podemos falar em revogação tácita ou por assimilação, como será discorrido;
11. A estipulação da alíquota e da base de cálculo do ITCMD no Espírito Santo não estão de acordo com a CF a partir de 21 de Dezembro de 2023 e, portanto, **os artigos 10, 12 e 13 da Lei 10.011/2013 foram - de imediato - revogados pela não recepção constitucional**;
12. A conclusão só pode ser no sentido de que **desde 21 de Dezembro de 2023 inexistiu legislação no ES que defina a alíquota ou a base de cálculo**;
13. Dessa forma, **é abusiva qualquer cobrança de ITCMD, como a que está para ser realizada contra a Impetrante**.



O principal ponto de discussão dessa peça é a **revogação** automática da lei infraconstitucional Estadual a partir da EC 132. Ao longo dos tópicos, ainda serão abordados temas que corroboram com a tese de inexistência total de alíquota, passando sobre assuntos como a **incompatibilidade material** de normas infra frente a Constituição Federal, **revogação** de lei infraconstitucional, **caducidade** e, ainda, sobre **o erro do consequencialismo judicial por motivos econômicos**.

Essa é uma discussão nova, como mencionado acima, e com forte apelo ao Direito Constitucional e Tributário, ainda que sua premissa básica (*não recepção*) seja assunto corriqueiro no judiciário.

Como era antes da mudança?

(vigente de 1988 até 21/12/2023)

A Constituição Federal instituiu, em seu art. 155, I o direito e a competência Estatal para tributar o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação. Abaixo, ve-se a versão **original (1988)** do preceito, que finalizava no artigo IV do parágrafo 1º - para esse tópico:

Art. 155. Compete aos **Estados** e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

§ 1º O imposto previsto no inciso I:

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado o de cujus, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

- a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;
- b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;

Versão Original do art. 155, CF, antes da EC 132/23



Vê-se que nesse texto original, nada se fala sobre a alíquota, se fixa ou progressiva, ou sobre a base de cálculo - se apenas sobre o quinhão ou cota-parte doada ou sobre o valor total do direito transmitido - elementos relevantes após a EC 132/2023.

Vale o destaque, ainda, que o texto original da CF de 1988, no seu artigo 155, parágrafo 1o, inciso IV, transfere ao Senado Federal a definição da alíquotas máximas de ITCMD: **IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal**. No caso, o Senado editou a Resolução n. 9 de 1992, ainda vigente, *in verbis*:

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 1992

Estabelece alíquota máxima para o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de que trata a alínea a, inciso I, e § 1º, inciso IV do art. 155 da Constituição Federal.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º **A alíquota máxima do imposto** de que trata a alínea a, inciso I, do art. 155 da Constituição Federal **será de oito por cento**, a partir de 1º de janeiro de 1992.

Art. 2º **As alíquotas** dos impostos, fixadas em lei estadual, **poderão ser progressivas** em função do quinhão que cada herdeiro efetivamente receber, nos termos da Constituição Federal.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, 5 de maio de 1991.

Adicionalmente, e a despeito da Carta Magna não ter expressamente autorizado o Senado a reger sobre progressividade ou não de alíquota, a Casa Legislativa admitiu que o ITCMD **poderia ser** progressivo, quando os Estados assim legislassem.

Em algum momento no passado houve uma discussão sobre a competência ou não do Senado em estipular a progressividade, questão essa alheia ao caso em tela e já pacificado no STF via Súmula 21 no sentido de reconhecer que, naquele momento, a progressividade era facultativa e, uma vez adotava, válida. **Esse cenário não prospera atualmente.**

Vale o registro: Essa Resolução de 1992 é o ato mais recente sobre o tema de definição de alíquota de ITCMD, e **apenas estipula o percentual máximo, nada falando sobre o mínimo.**

E aqui cabe uma pergunta: Existe alíquota mínima? Entendemos que não.



No campo Estatal, haja vista autorizações da CF e do Senado, o **Estado do ES decidiu pela alíquota fixa e base de cálculo sobre o valor total dos bens**/direitos transmitidos ou doados. É como se nota na lei mais recente que trata do ITCMD no ES, de n. 10.011/2013:

Art. 10. A **base de cálculo** do imposto é o **valor venal dos bens ou direitos** ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados. → **Nada menciona sobre quinhão ou cota-parte**

Art. 12. A **alíquota do imposto é de quatro por cento**. → **Alíquota fixa, e não progressiva**

Art. 13. O **valor do imposto a recolher será o resultado da aplicação da alíquota correspondente sobre a respectiva base de cálculo**. → **Nada menciona sobre quinhão ou cota-parte**

E assim o Estado do Espírito Santo operava, sem qualquer vício ou erro. Até a alteração constitucional.

Como É Agora? Mudança via EC 132: Base para a revogação da Lei Estadual

(a partir de 21/12/2023)

Pois bem. O cenário acima trazido **era** válido e vigente até a Emenda Constitucional n. 132 de 21 de Dezembro de 2023, que alterou e adicionou diversas espécies normativas na CF, dentre eles, o inédito inciso VI do art. 155, § 1º, a saber:

"Art. 155.

§ 1º

VI - será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação.

Com o novel inciso, nascem duas perguntas essenciais para o entendimento do presente caso:

- Ao usar a expressão "será", o Constituinte Derivado quis obrigar a progressividade ou deixar uma faculdade ao estado para, quando quiser, aderir à progressividade?
- Entendendo-se que "será" tem caráter obrigatório, a pergunta seguinte é: a partir de quando o dispositivo do Texto Maior tem sua validade, eficácia e vigência efetiva? Da promulgação? Só quando os Estados quiserem?



Antecipando-se a conclusão jurídica abaixo exposta, entendemos que o predicado verbo-nominal “será” gera uma obrigação clara e objetiva, fato esse confirmado não apenas pelo entendimento gramatical do termo, como também teleológico, pelo princípio da tipicidade cerrada e pela visão sistêmica; elementos esses detalhados abaixo e corroborados por **diversos julgados do STF**.

Ainda em sede antecipatória de conclusão, igualmente acreditamos que a aplicabilidade de tal obrigatoriedade é, de fato, imediata, vide a não-recepção pela CF de lei infraconstitucional conforme **inúmeros precedentes do STF**, sobretudo depois de passados 18 meses da promulgação sem a adequação pelo Estado.

São os dois pontos sobre os quais passamos a discorrer:

1. *Ratio legis*: A alíquota é de fato obrigatoriamente progressiva?
2. Da não-recepção Constitucional e da Revogação Imediata (STF)

1. Ratio legis: A alíquota é de fato obrigatoriamente progressiva?

- a. Interpretação Gramatical
- b. Interpretação Teleológica
- c. Interpretação pela Tipicidade Cerrada de Conceito Tributário
- d. Interpretação Sistêmica - que conduz à revogação imediata

Se antes havia uma ausência de pronunciamento constitucional sobre progressividade, escolheu o Legislador Constitucional Derivado via EC 132 **taxativamente dizer que “será progressivo” o ITCMD**.

Não raro, no entanto, vimos discussões judiciosas a respeito de interpretação gramatical que despreza regras linguísticas em prol de uma leitura pró-Fisco (*como se a palavra “será” não tivesse caráter imperativo, tal como um “poderá” é claramente facultativo*).

Queria o legislador constitucional expressamente obrigar à progressividade?

A resposta é óbvia: **sim**, tanto pela basilar **leitura gramatical** do inciso, como pela **teleologia**, como pelo **princípio da tipicidade cerrada**, como pela **visão sistêmica** da Legislação Pátria.



a. Visão Gramatical

Por mais desnecessário que possa parecer a explicação do caráter de obrigatoriedade do termo “será”, pede-se vênha apenas para não deixar dúvidas. De acordo com Cunha e Cintra⁴: “O modo indicativo [será], especialmente no futuro, exprime um fato tido como certo, real ou obrigatório, enquanto o verbo “poder” introduz a ideia de possibilidade ou permissão.”

Nessa linha foi o entendimento do STF em caso análogo. Naquele, a discussão foi ao redor do predicado “poderá”, concluindo os Ministros que o termo “poderá”, ao contrário do “será”, traz um caráter de permissão ou possibilidade:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. **O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal poderão ter alíquotas demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese.** Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.

Repita-se, em destaque: “**O emprego [pela EC] do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese**”. A mesma *ratio decendi* se vê no Tema 495 da Repercussão Geral, agora do Ministro Dias Toffoli.

4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter alíquotas que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.

Outros tantos julgados do STF reafirmam o leading case de entender a **diferença semântica entre “serão” e “poderão”**: ARE 1.349.153, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/11/2021; ARE 1.310.658, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29/4/2021; ARE 1.340.940, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/9/2021; ARE 1.309.537, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/8/2021; ARE 1.353.467, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2021; ARE 1.147.146, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/6/2021; ARE 1.185.369, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/2/2021.

⁴ CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 2008.



Ora, a lógica do predicado verbo-nominal é exatamente a mesma, mas no caso da EC 132/32 não houve a escolha exemplificativa ou facultativa do “poderão”, mas a taxatividade do “serão”, ou, in casu, “será progressiva”.

b. Visão Teleológica

No direito brasileiro, **teleologia** busca identificar a finalidade e o espírito da lei. A interpretação teleológica **busca compreender a razão que motivou a criação/alteração da lei**, para que seja possível interpretá-la de forma mais eficiente.

No afã de entender a motivação / teleologia da lei constitucional, não encontramos menções de discussões mantidas pelos Deputados e Senadores Constituintes Derivados especificamente quanto ao novo inciso IV do artigo 155, par. 1o, **mas encontramos a outrora motivação e discussão legislativa clara e objetiva em relação à decisão para adicionar a progressividade do imposto irmão do ITCMD, o ITR - Imposto Territorial Rural, assim disposto no art. 153/CF:**

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

VI - **propriedade territorial rural**;

§ 4º O imposto previsto no inciso VI do caput:

I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas;

Veja a repetição do predicado verbo-nominal “será progressivo”. E nesse ponto, os Constituintes assim se **manifestaram no Relatório da PEC 228 sobre o entendimento de “será progressivo”:**

Relatório PEC 228

Vem a esta Comissão, na forma regimental, para exame prévio de admissibilidade, a PEC nº 228, de 2004, oriunda do Senado Federal.

Art. 153, § 4º, I, II e III. Promulgado. I - **será progressivo** e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas;

Ratio: Trata do ITR (imposto territorial rural), que passa a ser **imperativamente progressivo** e cuja administração e arrecadação poderá passar para os municípios que assim optarem mediante convênios.⁵

⁵ <https://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/195940.htm>



A escolha do predicado verbo-nominal “será progressivo” foi declaradamente intencional, tal como se mostra nas razões e motivações legislativas constitucionais do ITR, vide Relatório da PEC acima colacionada indicando a imperatividade da progressividade.

c. Visão pela Tipicidade Cerrada

Tem-se, ainda, que o Direito Tributário é também composto de garantias ao contribuinte, uma delas a do Princípio da Legalidade, que tem em um de seus corolários a **Tipicidade Cerrada**. Em obra do renomado Ricardo Lobo Torres, citando Alberto Xavier, vimos a relevância da tipicidade cerrada:

O princípio da tipicidade é um corolário do princípio da legalidade. Este último, em sentido lato, pode abranger os diversos princípios de segurança jurídica: irretroatividade, anterioridade, proibição de analogia, etc. Mas, pela sua relevância e conteúdo, a tipicidade deve ser tratada como princípio específico de segurança jurídica

[...]

Importantíssima foi a contribuição de Alberto Xavier ao tema da tipicidade, ao afirmar: “a tipicidade do Direito Tributário é, pois, segundo certa terminologia, uma tipicidade fechada: contém em si todos os elementos para a valoração dos fatos e produção dos efeitos, sem carecer de qualquer recurso a elementos a ela estranhos e sem tolerar qualquer valoração que se substitua ou acresce à contida no tipo legal”⁶

Se a norma tributária, pela tipicidade cerrada, precisa conter todos os elementos para a valoração dos fatos e da produção de seus efeitos, impossível esperar que o inciso IV do art 155 par. 1o, estivesse dependente de uma ilação gramatical sobre a elasticidade do conceito de “será progressivo”.

Se por um lado o Fisco tem as proteções de interpretação restritiva da norma no quesito de isenções (art. 111, CTN), por outro, a tipicidade cerrada impede que a lei tributária seja lida por analogia ou a contrário senso. A norma deve, conforme Alberto Xavier acima, conter todos os elementos para sua valoração.

“Será progressiva” é, em si, a totalidade de elementos para valorar fatos, valores e efeitos. “Poderá” não faz parte da tipicidade cerrada da inclusão legislativa constitucional.

⁶ Torres, R. L. (2004). O princípio da tipicidade no direito tributário. Revista De Direito Administrativo, 235, 193–232. <https://doi.org/10.12660/rda.v235.2004.45134>



d. Visão Sistêmica

A legislação tributária, além de interpretação gramatical, por tipicidade cerrada/legalidade e/ou teleológica, **também deve ser sistêmica**, o que traz consigo o ponto de conexão entre a *ratio legis* (*imperatividade progressiva*) e o entendimento sobre a extensão da aplicabilidade da norma modificante (*não recepção automática das leis em contrário*).

CTN

Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

Nessa visão holística do sistema jurídico, portanto, podemos citar outros normativos que discorrem sobre vigência, revogação e efeitos, tais como:

LICC / LINDB

"Artigo 2, CC — Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior".

CF

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

c/c

Art. 146, III:

a) **definição de tributos e de suas espécies**, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos **atos geradores, bases de cálculo e contribuintes**;⁷

Na junção dos três artigos acima colacionados, temos que a EC 132 é uma lei nova - superveniente -, de hierarquia superior às leis infraconstitucionais, e o novo inciso VI do § 1º do art 155 ("será progressivo") trouxe uma alteração que - em si, já regula a matéria de norma geral como um todo (art. 146, CF), de modo que revoga a lei anterior (art. 2º LICC) e suspende a eficácia de lei estadual (art. 24, CF) com ela incompatível.

⁷ O novel artigo 155, I, parágrafo 1º, inciso IV ("alíquota progressiva") define norma geral, e contém em si os elementos para composição da base de cálculo e o regramento matriz de incidência e aplicação tributária, seja no quesito de progressividade ou não da alíquota como quanto ao cálculo baseado no quinhão ou cota-parte transmitido ou doado.



Vale reforçar o ponto de que o papel da Carta Magna, nesta seara, é o de se limitar à “norma geral” de incidência tributária para que seja válida. Dito de outra forma, a vigência do inciso VI, art 155, CF (progressividade) **não está condicionada à uma edição de lei complementar (federal ou estadual)**. A aplicação é imediata, posto que **toda** norma geral foi ali tratada, o que suspende lei estadual com ela em contrário (art. 24 CF). É sobre o que passamos a expor.

2. Da não-recepção Constitucional e da Revogação Imediata (STF)

O instituto da **recepção constitucional** pode ser definido como o processo pelo qual uma nova Constituição ou uma emenda constitucional reconhece como válidas as normas infraconstitucionais preexistentes, desde que estas sejam **materialmente** compatíveis com o novo ordenamento jurídico.

Por outro lado, a **não-recepção ocorre quando normas infraconstitucionais anteriores deixam de ser válidas por não se adequarem materialmente** ao conteúdo da nova Constituição ou da emenda constitucional.

O instituto da não recepção tem o efeito prático similar ao do reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei, ambos com o poder de extirpar tal legislação do sistema jurídico.

No entanto, **o STF não admite a “inconstitucionalidade superveniente”**, ou seja, leis anteriores à CF ou Emendas Constitucionais que sejam com elas incompatíveis não serão declaradas inconstitucionais, **mas não-recepcionadas**, restando-se **revogadas** desde a data da vigência da alteração da Lei Maior.

Esse é disposto na ADI 02 desde 1992:

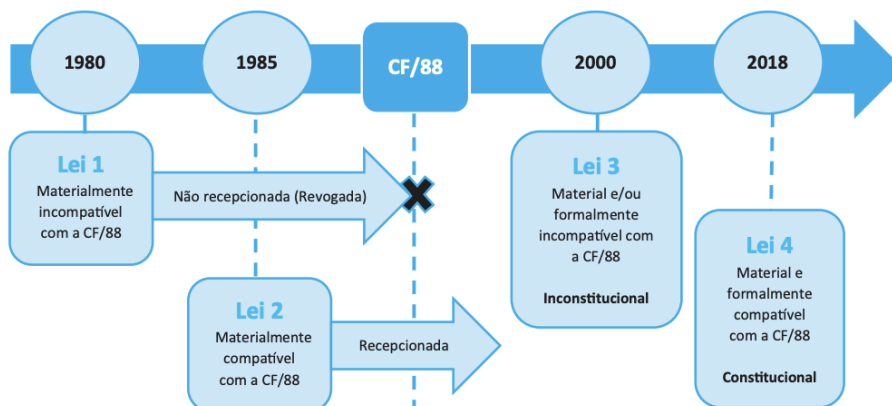
STF - ADI: 2 DF, Relator.: Min . PAULO BROSSARD, Data de Julgamento: **06/02/1992**, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 21-11-1997 PP-60585 EMENT VOL-01892-01 PP-00001 CONSTITUIÇÃO. LEI ANTERIOR QUE A CONTRARIE. REVOGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A lei ou é constitucional ou não é lei. Lei inconstitucional é uma contradição em si. A lei é constitucional quando fiel à Constituição; inconstitucional na medida em que a desrespeita, dispondo sobre o que lhe era vedado. O vício da inconstitucionalidade é congênito à lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de sua elaboração. **Lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente**; nem o legislador poderia infringir Constituição futura. **A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitantes: revoga-as**. Pelo fato de ser superior, a Constituição não deixa de produzir efeitos revogatórios. **Seria ilógico que a lei fundamental, por ser suprema, não revogasse, ao ser promulgada, leis ordinárias.** A lei maior valeria menos que a lei ordinária.



Alguns operadores do direito podem ter uma equivocada leitura desse julgado, ou fazer recortes que passem uma falsa leitura do contexto judicante como um todo. Se por um lado há um trecho que cita que “lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente”, por outro, esse recorte não pode ser lido isoladamente.

Não estão os Ministros a dizer que “as leis anteriores permanecem válidas e constitucionais mesmo diante uma nova ordem constitucional”. A discussão naquele julgado clássico é uma **aula sobre a diferença de “inconstitucionalidade superveniente” frente “não-receptividade”**, sendo que em ambos os cenários operaria-se a **revogação da lei incompatível**. É o que se aduz pela leitura da frase seguinte, ora repetida: **“A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitantes: revoga-as. Seria ilógico que a lei fundamental, por ser suprema, não revogasse, ao ser promulgada, leis ordinárias”**

Emprestando-nos de fluxograma disposto no Manual de Direito Constitucional do Professor Eduardo dos Santos⁸, vide a cronologia da recepção ou inconstitucionalidade da seguinte forma:



Desta feita, as normas não-recepcionadas não são objeto de controle de constitucionalidade. A análise da recepção é automática quando se tornam incompatíveis⁹ e seus efeitos se operam desde a promulgação do novo texto constitucional (ADI 02/STF), **cabendo ao controle difuso e à qualquer julgador** do Poder Judiciário, em qualquer ação, **aplicar a não-recepção da norma infraconstitucional** no caso concreto.

⁸ Dos SANTOS, Eduardo. Manual de Direito Constitucional, 4a ed, 2023, Ed. Jus Podivm, p. 180

⁹ KELSEN, Hans. Teoria do direito e do Estado. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 172.



- Posição Atual do STF sobre a não recepção de leis incompatíveis após EC

Entendido o instituto da recepção, passa-se a abordar a visão moderna do STF sobre o tema. A não-recepção de lei tributária infraconstitucional, independente da razão e forma de interpretação (*gramatical, tipicidade fechada, teleologia, histórica ou sistêmica*) é matéria batida no judiciário, seja nas Cortes Superiores ou de base, colacionando-se abaixo julgados que remontam aos últimos 20 anos:

(STF - ADI: 7743 MT, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: **28/11/2024**, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28/11/2024 PUBLIC 29/11/2024) Conforme jurisprudência desta Corte, verifica-se a prejudicialidade das ações de controle de constitucionalidade abstrato por perda superveniente de objeto quando sobrevém **a revogação da norma questionada**, o exaurimento de sua eficácia ou alteração substancial do conteúdo normativo impugnado. Veja-se: ADI nº 6.416-AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/21); ADI nº 5.987/AM AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/21); ADI nº 5.145/MA AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/20); ADI nº 2.049/RJ (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/19); ADI nº 4.389-AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/18); e ADI nº 1.378 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/11). É certo, ademais, **que a jurisprudência também admite a prejudicialidade por revogação tácita** do objeto impugnado (v.g. ADI nº 4583/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/20; ADI nº 2352/ES, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/11; ADI nº 1.056/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 3/10/97; ADI nº 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ de 24/6/1994; ADI nº 2.006/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 10/10/08; ADI nº 3.831/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/07; ADI nº 1.920/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 2/2/07; ADI nº 1.952/DF-QO, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 9/8/02; ADI nº 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 6/6/97). In casu, portanto, forçoso concluir que a presente ação direta de inconstitucionalidade não comporta conhecimento, **porquanto seu objeto foi tacitamente revogado por legislação superveniente, não impugnada pelo requerente.**

(STF - ADI: 4984 CE, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 12/04/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/04/2018) CONSTITUCIONAL. LEIS COMPLEMENTARES 1/1994 E 84/2009 DO ESTADO DO CEARÁ. NORMAS GERAIS. ESTUDOS DE VIABILIDADE MUNICIPAL . EC 15/1996. NOVA CONFORMAÇÃO DA MATÉRIA. LEI ESTADUAL REVOGADA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FIXAR PERÍODO DE CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE MUNICÍPIOS . ESTABELECIMENTO DE DEVERES E OBRIGAÇÕES PARA A JUSTIÇA ELEITORAL POR MEIO DE LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA, NESSE PONTO. 1 . **A promulgação de Emenda Constitucional enseja revogação dos atos normativos anteriores que lhe são contrários.** 2. Competência da União para fixar lapso temporal em que permitida a criação, a incorporação, a fusão ou o desmembramento de municípios (CF, art. 18, § 4º, com redação dada pela EC 15/1996) . 3. A União é competente para estabelecer normas gerais acerca do processo de criação de municípios, o que não obsta a competência suplementar dos Estados-Membros. 4. Impossibilidade de criação, fusão, incorporação ou desmembramento de municípios antes do advento de Lei Complementar federal definindo o período em que autorizado . 5. Os Estados-Membros são incompetentes para designar obrigações para a Justiça Eleitoral, que integra a Justiça Federal. 6. Ação julgada parcialmente procedente .



(STF - ARE: 825237 RJ, Relator.: Min . ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 31-10-2014 PUBLIC 03-11-2014) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO . **REVOGAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. POSSIBILIDADE.** PRECEDENTES . Não há direito adquirido a regime jurídico de imunidade tributária. Ademais, nos termos da jurisprudência da Corte, a disposição revogada não consagra direito ou garantia fundamental. Agravo regimental a que se nega provimento.

(TJ-MG 100000027501980001 MG 1 .0000.00.275019-8/000(1), Relator.: MARIA ELZA, Data de Julgamento: 05/09/2002, Data de Publicação: 15/10/2002) Contribuição previdenciária - Inativos - Lei n 12.278/96 - Admissibilidade - Inconstitucionalidade não declarada - Sentença que se reforma. V.V .P. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS. NÃO RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 20. De acordo com entendimento firme do Supremo Tribunal Federal, o art . 2º, IV, e **a expressão ""proventos de aposentadoria"" do art. 3º, ambos da Lei Estadual 12.278/96, não foram recepcionados pela nova ordem constitucional previdenciária estabelecida pela Emenda Constitucional 20/98**, que proíbe a instituição e cobrança de contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos.

Nota-se que em todos esses julgados, o reconhecimento da não-recepção foram, todos, pela modalidade tácita, e não revogação expressa. Há uma concepção errada de alguns juristas de que a revogação da lei precisa ser expressa.

Essa errada concepção de que a revogação expressa é necessária vem da interpretação limitada e equivocada do art. 9º da Lei Complementar 95 de 1998, que dispõe, a mando da CF, sobre as Normas de Consolidação de Atos Normativos:

LC 95/1998

Art. 9º A cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as leis ou disposições legais revogadas.

Numa primeira leitura desatenta, poder-se-ia ter a atravessada conclusão de que “qualquer revogação deverá enumerar expressamente” os textos revogados. **Engano.** A leitura gramatical é de que, **quando expressa**, a revogação deve enumerar o que está revogando. E esse entendimento não extirpa o instituto da revogação tácita.

Aliás, até mesmo quando das discussões do congresso sobre o projeto de lei que depois viraria a LC 95 de 1998 (*teleologia*), a dúvida sobre ser ou não necessário revogar expressamente foi abordado - e esclarecido.



O Deputado Federal Roberto Magalhães, relator do voto do art. 9 da LC 95/1998 na Comissão de Constituição e Justiça no Congresso, **rejeitou** uma subemenda ao próprio artigo 9 que, ai sim, teria tornado obrigatória a expressa revogação de lei:

"Indubitavelmente, a revogação expressa dos dispositivos contrários ao novo ato normativo que surge no ordenamento jurídico é medida conveniente e adequada.

A menção — no próprio corpo da norma — daqueles dispositivos a ela anteriores e contrários, facilita, sobremaneira, a aplicação da nova lei.

Entretanto, impossível ignorar o fato de que o ordenamento jurídico brasileiro é de tal forma complexo, que a revogação expressa, muitas vezes, restará falha. Neste país, não são poucos os casos de normas derogadas, que sobrevivem com um ou dois dispositivos, mesmos após a revogação da maior parte de seu texto.

(...)"

Na sequência, inclusive, apresentou uma subemenda no sentido de que a revogação expressa deveria se dar "sempre que possível", mas no final a retirou, e votou contra a emenda por considerá-la ineficaz, visto que "a lei de introdução ao Código Civil já regulou suficientemente este assunto não havendo, pois, porque alterar sua sistemática".

A lógica dos legisladores foi sistêmica, ao entender que "a lei de introdução ao Código Civil já regulou suficientemente este assunto", se referindo, pois, às revogações expressa, tácita e por assimilação de leis anteriores quando incompatíveis com as posteriores.

LICC / LINDB

"Artigo 2, CC — Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior".

De maneira mais didática, o §1º do art. 2 da LICC elenca três formas de revogação de lei:

1. **Expressa:** "quando expressamente o declare"
2. **Tácita:** "quando seja com ela incompatível"
3. **Por Assimilação:** "quando regulamente inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior".



A **revogação expressa** é, como dito, aquela declarada. Ela pode ser nominal (*revogam-se artigos XYZ*) ou pode ser inominada (*revogam-se todas as leis em contrário*). A própria Emenda Constitucional n. 132 de 2023 trouxe revogações expressas, por exemplo:

Art. 22. Revogam-se:

I - em 2027, o art. 195, I, "b", e IV, e § 12, da Constituição Federal;

II - em 2033:

a) os arts. 155, II, e §§ 2º a 5º, 156, III, e § 3º, 158, IV, "a", e § 1º, e 161, I, da Constituição Federal; e

b) os arts. 80, II, 82, § 2º, e 83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Por outro lado, o fato de ter algumas revogações expressas não significa que não se podem ter outras tácitas. Escolheu o Constituinte Derivado na EC 132 não incluir expressamente a revogação milhares de artigos e normativos estaduais que versam sobre o ITCMD, sua base de cálculo e/ou progressividade da alíquota. O Legislador Constitucional simplesmente não sabe - e nem precisa saber - de toda a legislação estadual, sendo o instituto da revogação tácita pela não-receptividade suficiente para adequar o sistema jurídico como um todo.

Por outro lado, é um **falso** silogismo entender que por não ter havido uma revogação expressa, não revogadas estão as leis incompatíveis.

O Professor Adrian Sgarbi, Titular da Cadeira de Teoria do Direito da PUC-RJ e pós-Doutor em Direito pela USP, publicou um detalhado artigo sobre Revogação de Leis no Tomo de Teoria Geral e Filosofia do Direito da PUC-SP, onde reflete sobre a naturalidade da eliminação de normas:

"Eliminar normas é mecanismo relacionado à dinâmica do direito e, particularmente, à propriedade de sua mudança através de operações reguladas pelo próprio ordenamento jurídico. De fato, as normas jurídicas permanecem no conjunto normativo até que determinação de autoridade **normativa** resulte em sua exclusão. **A este respeito, cumpre lembrar que a técnica de eliminar uma norma de um conjunto normativo pode assumir distintas formas.**"¹⁰

O professor Sgarbi aduz que **"Por "revogação tácita" designa-se a eliminação da vigência de uma norma por apresentar-se incompatível com outra norma [...] deve-se destacar a proximidade existente entre a revogação "tácita" e a revogação "expressa inominada"**

¹⁰ SGARBI, Adrian. Revogação. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Teoria Geral e Filosofia do Direito. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017.



Completa:

Relativamente à “revogação tácita” e “por assimilação”, pode-se diferenciá-las pelo fato de a revogação tácita ser uma revogação entre normas ao passo que a **revogação por assimilação é, à semelhança da revogação expressa**, uma revogação de textos (“A lei posterior revoga a anterior quando (...) regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”);

Ademais, a “**revogação tácita**” exige “**incompatibilidade**”, enquanto que a “**revogação por assimilação**” exige a “**inteira regulação da matéria**”, ainda que comparadas em suas respectivas dicções textuais se possa, entre elas, encontrar compatibilidades fracionárias;

A EC 132/23 valeu-se de várias formas de eliminação de normas, seja pela da revogação expressa (como no art. 22 acima transcrito) como também pela revogação tácita e por assimilação, haja visto que o art. 155, § 1o, VI trata, em si, a totalidade do tema do ITCMD no que toca à norma geral (art. 146, CF) competente à CF (ainda que o específico - não norma geral - caiba aos estados). Nas palavras do pós-Doutor Professor Adrian Sgarbi “*um só artigo pode revogar - por assimilação ou tacitamente - todo um código*”.

Voltemos um pouco para entender melhor este ponto. A Carta Magna estabelece a regra geral tributária, definindo as competências, hipóteses tributárias e limites no que toca ao fato gerador e base de cálculo. A leitura sistêmica assim dispõe:

CTN

Art. 18. **Compete:**

I - **à União, instituir**, nos Territórios Federais, **os impostos atribuídos aos Estados** e, se aqueles não forem divididos em Municípios, cumulativamente, os atribuídos a estes;

CF

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar **concorrentemente** sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer **normas gerais**.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre **normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.**

Art. 146, III: Cabe à lei complementar

a) **definição de tributos e de suas espécies**, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos **atos geradores, bases de cálculo e contribuintes**;¹¹ → **definição de “normas gerais”**

¹¹ O novel artigo 155, I, parágrafo 1o, inciso IV (“alíquota progressiva”) define norma geral, e contém em si os elementos para composição da base de cálculo e o regramento matriz de incidência e aplicação tributária, seja no quesito de progressividade ou não da alíquota como quanto ao cálculo baseado no quinhão ou cota-parte transmitido ou doado.



É dizer, a norma geral da regra matriz é função Constitucional, e a foi feita à totalidade quando a EC trouxe o texto “será progressivo”. Esse superveniente texto, portanto e à luz do § 4º do art. 24, é começo, meio e fim de uma norma geral, dentro dos limites constitucionais, que, assim, suspende eficácia de lei estadual.

E não se argumente que o art. 146, III da CF obriga que uma lei complementar (*federal ou estadual*) defina a norma geral, como se o inciso constitucional por si só não o pudesse fazê-lo em termos de normativo abstrato/geral. Renomados autores como Paulo de Barros Carvalho e Roque Carrazza¹², entendem que a Lei Complementar referida pelo art. 146, III, CF está constricta a apenas dispor sobre conflitos de competência entre os Entes Federados ou à **regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar, sendo o inciso III, alínea “a” um dispositivo que apenas valida a norma geral estabelecida pela CF em artigos de caráter tributários.**

A revogação tácita ou por assimilação exige “incompatibilidade material”, o que já fora deveras demonstrado quando dos tópicos da vontade clara e expressa do legislador constituinte em escolher o predicado verbo-nominal “será progressivo” ao revés de “poderá”.

Incompatibilidade evidenciada acima, cabe a esse capítulo expor como a jurisprudência do STF vem aplicando a revogação tácita. Para ilustrar essa autorização e permissão, renova-se o recente julgado de Novembro de 2024 do STF na ADI 7743, pelo Ministro Dias Toffoli:

(STF - ADI: 7743 MT, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: **28/11/2024**, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28/11/2024 PUBLIC 29/11/2024)

Conforme jurisprudência desta Corte, verifica-se a prejudicialidade das ações de controle de constitucionalidade abstrato por perda superveniente de objeto quando sobrevém **a revogação da norma questionada**, o exaurimento de sua eficácia ou alteração substancial do conteúdo normativo impugnado. Veja-se: ADI nº 6.416-AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/21); ADI nº 5.987/AM AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/21); ADI nº 5.145/MA AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/20); ADI nº 2.049/RJ (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/19); ADI nº 4.389-AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/18); e ADI nº 1.378 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/11).

É certo, ademais, **que a jurisprudência também admite a prejudicialidade por revogação tácita** do objeto impugnado [...]. In casu, portanto, forçoso concluir que a presente ação direta de inconstitucionalidade não comporta conhecimento, **porquanto seu objeto foi tacitamente revogado por legislação superveniente, não impugnada pelo requerente.**

¹² CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 15. Ed., p. 210-211; CARRAZZA, Roque, Curso de Direito Constitucional Tributário, 12. Ed., p. 510



No mesmo sentido:

ADI nº 4583/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/20
ADI nº 2352/ES, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/11
ADI nº 1.056/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 3/10/97
ADI nº 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ de 24/6/1994
ADI nº 2.006/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 10/10/08
ADI nº 3.831/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/07
ADI nº 1.920/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 2/2/07
ADI nº 1.952/DF-QO, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 9/8/02
ADI nº 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 6/6/97

Mas não apenas o STF reconhece a extirpação de lei por revogação tácita. Em se tratando de matéria tributária, o CARF tem grande relevância jurisprudencial e também acolhe a revogação tácita, a despeito de, por vezes, ter um olhar pró-Fisco. Recorremos ao excelente artigo do Professor Diego Diniz Ribeiro (*Direto do CARF: Revogação tácita e revogação expressa à luz da jurisprudência do Carf*¹³), que assim compartilha:

Nesse sentido, a primeira decisão a ser analisada está veiculada no **acórdão Carf nº 3101-000.256**. Nesse caso, o contribuinte alegava a nulidade do lançamento perpetrado ao fundamento de erro na sua motivação. Segundo o contribuinte, o lançamento da multa de 50% pelo não retorno ao exterior de mercadoria submetida ao regime de admissão temporária deveria ter sido capitulado no artigo 106, inciso II, "b", do Decreto-Lei nº 37/66, e não no disposto no artigo 72, inciso I, da Lei 10.833/03, uma vez que esse último prescritivo legal não teria expressamente revogado o primeiro, o que conflitaria com o artigo 9º da citada Lei Complementar 95/98. **Ao analisar a questão, o relator do caso, acompanhado por unanimidade, aduziu que o artigo 9º da LC nº 95/98, aboliu a chamada revogação genérica, traduzida pela expressão "revogam-se as disposições em contrário", mas que, todavia, não desapareceu do sistema jurídico a revogação tácita, porquanto é impossível ao legislador ter presente, o tempo todo, a perfeita compreensão dos efeitos que as normas jurídicas contidas no texto legal terão sobre as demais normas já constantes do sistema jurídico.**

Parece haver uma confusão aqui: o entendimento do Carf e do STJ é, de fato, no sentido de não ter ocorrido a revogação tácita do artigo 77, II, da Lei nº 8.981/95, pelo artigo 5º da Lei nº 9.779/99, e não no sentido de rejeitar a revogação tácita enquanto instituto, o que são coisas distintas. **A jurisprudência do Carf, como demonstrado acima, nunca adotou essa linha [de rejeitar a revogação tácita], ao passo que a Primeira Seção do STJ, no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.050.430 [14], pacificou a inocorrência de revogação tácita nesse caso, mas pontou em seu voto que "Há revogação tácita quando, de forma implícita, há incompatibilidade entre o texto anterior e o posterior. Segundo a melhor doutrina, essa incompatibilidade deve ser absoluta. Não pode partir de meras presunções",** rejeitando expressamente a exigência de revogação expressa.

No acórdão **Carf nº 1301-002.974, reconheceu-se a possibilidade expressa de revogação tácita, com base no artigo 2º, §1º, da LINDB**, mas rejeitou-se sua ocorrência no caso concreto, em relação a uma pleiteada revogação do artigo 42 da Lei nº 9.430/96 pelo artigo 5º, §4º, da LC nº 105/2001.

¹³ <https://www.conjur.com.br/2020-jul-01/direto-carf-revogacoes-tacita-expressa-luz-jurisprudencia-carf/>



Reitera-se, tanto em referência ao julgado de Novembro de 2024 do STF na ADI 7743 como nas decisões do CARF acima, que em todos os casos de revogação tácita está a se falar de um artigo específico, e não de um compêndio de disposições dentro de uma Lei Complementar ou Ordinária, o que reforça, mais uma vez, que a matéria de revogação, quando amparada na LICC, art. 2º, par. 1º, não entende a palavra “lei” no seu sentido técnico restrito, mas amplo para entender quaisquer documentos normativos, disposições legais, normas, conceitos, costumes, artigos, parágrafos, incisos, etc.

Vimos acima que a interpretação **gramatical** do inciso VI é clara ao ter usado o predicado verbo-nominal “será” numa conclusão bem diferente de “poderá”; onde “será” é obrigatório e “poderá” seria facultativo. Para não deixar dúvidas, abusamos da explicação **teleológica** ao transcrever as discussões e *ratio* dos Deputados quando da definição do “será progressivo” em relação ao ITR (imposto também de norma geral da CF) quando de sua alteração via PEC 228/04.

Ainda trouxemos o **princípio da legalidade e tipicidade cerrada**, para além da **visão sistêmica** de interpretação das leis, para ler de maneira holística a alteração Constitucional Derivada, quando mencionamos sobre o art. 9º da LC 95 de 1998 e o artigo 2º, par 1º da LICC, tudo numa visão sistêmica que inclui o art. 114 do CTN, e os artigos 24 c/c 146 da CF.

Concluimos com mais de 20 julgados do STF e do CARF que reconhecem a revogação tácita imediata frente a não-receptividade de lei infraconstitucional, com destaque ao Tema 375 que, em tema deveras similar, foi expresso ao diferenciar o entendimento de “poderá” *versus* “será” progressiva a alíquota, o que corrobora com nosso argumento ora apresentado.

Todas as legislações citadas levam a conclusão de que a EC 132 instituiu a obrigatoriedade da progressividade o que, de imediato a partir de 21/Dez/2023, operou a “não-receptividade” de qualquer lei em contrário, incluindo os artigos 10, 12 e 13 da Lei Estadual 10.011/2013.

Assim, só tem uma conclusão a chegar: **não existe hipótese de incidência (nos seus elementos de regra-matriz alíquota e base de cálculo) em vigência para fins de ITCMD no Estado do Espírito Santo**, sendo nula qualquer cobrança por ausência de lei que a anteceda.



Efeito: Inexistência de legislação que define a alíquota do ITCMD no ES

(Art. 150, CF: Vedada a exação de tributos sem lei que o antecede)

Nesse capítulo, vamos nos referir apenas à conclusão: **não existe no ordenamento jurídico estadual a definição válida ou vigente de alíquota ou base de cálculo para ITCMD**. Não havendo lei válida sobre o tema, não há cobrança tributária a ser feita. Qualquer cobrança de ITCMD no ES a partir de 21/Dez/ de 2023 é abuso do Poder Público. Vide art. 150, CF, *in verbis*:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é **vedado** à União, **aos Estados**, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – **exigir** ou aumentar **tributo sem lei que o estabeleça**;

Abordamos acima o art. 24 da Carta Magna, que apregoa a competência concorrential em tributar entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal. É de entendimento geral que **na ausência** de normativo federal, os estados podem exercer a competência supletiva.

Era o que acontecia, a propósito. Como a CF não detalhava a norma geral do ITCMD, os estados escolhiam ou não a progressividade do ITCMD. Existia uma ausência de normativo federal sobre o tema de norma geral e, pela suplência, os Estados assim regulavam.

Por outro lado, o caso atualmente é deveras diferente. A lei constitucional agora **expressamente** abordou a norma geral, o que há quase 40 anos não o tinha feito. E aí que o parágrafo 1o do mesmo artigo 24, CF é aplicável ao dizer que a **superveniência de preceito federal sobre normal geral** (*regra-matriz de tributo, que inclui alíquota e base de cálculo*) **suspende a eficácia de lei estadual que lhe for contrária**.

É inconstitucional a exigência de tributo sem a devida previsão legal, sendo vedada a criação de obrigação tributária por ato infralegal" (STF, ADI 5.135/DF, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, DJ 26/09/2019).

A EC n. 132 entrou em vigor no dia 21 de Dezembro de 2023. A partir desta data os artigos 10, 12 e 13 da Lei Estadual 10.011/2013 foram extirpados e, assim, vedada está qualquer cobrança de ITCMD, por força do art. 150, CF, pelo que se requer, ao final, que proteja o interesse do contribuinte nesse *writ* e evite que seja, contra si, emitida cobrança e/ou que seja aberto processo administrativo no que toca ao pagamento de ITCMD em relação à cessão não onerosa que se operou pela doação de cotas societárias detalhadas no preâmbulo fático.



Meritoriamente, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, quais sejam, o **fumus boni iuris** e o **periculum in mora**, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema.

O **fumus boni iuris** está plenamente caracterizado pela ausência de base legal válida para a exigência do ITCMD no Estado do Espírito Santo, uma vez que, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 132/2023, em 21 de dezembro de 2023, foram automaticamente revogados os artigos 10, 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.011/2013, os quais disciplinavam a hipótese de incidência do tributo.

Nos termos do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, **é vedada a exigência de tributo sem previsão legal específica**, o que significa que nenhum ITCMD pode ser cobrado pelo Estado do Espírito Santo até que nova legislação seja editada em conformidade com a nova sistemática constitucional.

A jurisprudência do STF já pacificou que a inexistência de norma válida impede a exigibilidade do tributo, uma vez que o princípio da legalidade tributária é um dos pilares da segurança jurídica. A título exemplificativo:

É inconstitucional a exigência de tributo sem a devida previsão legal, sendo vedada a criação de obrigação tributária por ato infralegal" (STF, ADI 5.135/DF, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, DJ 26/09/2019).

Portanto, qualquer tentativa do Fisco Estadual de cobrar ITCMD sobre a cessão não onerosa de cotas societárias objeto deste *writ* configura abuso de poder e violação direta à Constituição Federal, devendo ser afastada liminarmente.

O **periculum in mora** decorre do iminente risco de o Impetrante ser ilegalmente compelido a recolher ITCMD com base em uma legislação inexistente, sob pena de:

- Recebimento de guia de pagamento indevida, baseada em normas revogadas e inconstitucionais;
- Abertura de processo administrativo tributário, sujeitando eventual cobrança coercitiva pelo Estado;
- Possível inscrição em dívida ativa e execução fiscal indevida, caso não haja pagamento do tributo que sequer possui fundamento legal vigente.



O STJ é uníssono em aceitar o Mandado de Segurança Preventivo na esfera tributária, aduzindo, ainda, **que o writ é cabível para evitar que a autoridade coatora proceda ao lançamento fiscal ilegal**, uma vez que, à luz do art. 142, CTN, o lançamento tributário é atividade administrativa vinculada e obrigatória:

Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

STJ: EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.169.402 - SP (2017/0230136-2)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ISS SOBRE ATIVIDADES EXERCIDAS POR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS. ACÓRDÃO EMBARGADO FIRMADO COM BASE EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO PARA AFASTAR O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DO WRIT OF MANDAMUS NA MODALIDADE PREVENTIVA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE LANÇAMENTOS FISCAIS REGULARMENTE INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, A FIM DE PROVER O RECURSO ESPECIAL, PARA, RECONHECENDO O CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIÇÃO DAS QUESTÕES REMANESCENTES.

Outros Precedentes no STJ: AgInt no REsp. 1.270.600/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 13.6.2018; AgRg no AREsp. 543.226/PE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.12.2015; AgRg no Ag 1.302.289/RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 8.11.2010; REsp. 860.538/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16.10.2008.

No caso dos autos, o writ se justifica na medida em que a Contribuinte objetiva evitar que atos abusivos de cobrança venham ocorrer, haja vista que o Estado do ES não suspendeu as cobranças de ITCMD desde a revogação da lei estadual pela não recepção e, pelo contrário, o estado acredita estar obrigado - por força do art. 142, CTN, a proceder com as cobranças de 4% sobre o valor da doação para fins de ITCMD.

A exigência ilegal do ITCMD, se não impedida de imediato, levaria o Impetrante a um ônus desnecessário e ilegal, obrigando-o a quitar um tributo inexistente para, posteriormente, ingressar com ação regressiva, submetendo-se a um longo e custoso processo judicial.



O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de concessão de liminar em mandado de segurança preventivo para impedir exigências tributárias sem base legal válida, evitando que o contribuinte seja indevidamente prejudicado:

"É cabível a concessão de liminar em mandado de segurança para afastar a exigência de tributo, quando inexistente base legal para sua cobrança, evitando-se a submissão do contribuinte a cobrança indevida e necessidade de repetição de indébito." (STJ, AgInt no RMS 66.108/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 16/12/2022).

Dessa forma, impedir o Estado do Espírito Santo de exigir ITCMD sem norma válida é medida de rigor, sob pena de afronta direta à legalidade tributária e segurança jurídica.

Ademais, o artigo 151, IV, do CTN prevê que a (*pretensa*) exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa por concessão de medida liminar em mandado de segurança, hipótese que se aplica perfeitamente ao presente caso, pois há evidente ausência de base legal válida para a cobrança do ITCMD.

Diante do exposto, não há dúvidas de que o Impetrante possui direito líquido e certo de não ser compelido ao pagamento de ITCMD enquanto não houver lei estadual válida regulamentando sua exigência.

DOS PEDIDOS

Diante da robustez dos fundamentos apresentados, requer-se:

1. A concessão da medida liminar, *inaudita altera parte*, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de emitir guias e/ou cobrar ITCMD em relação às Declarações n. 20250000011982, 20250000011988 e 20250000011989, diante do *fumus bonis iuris*, *periculum in mora* e a ausência de prejuízo ao Estado;
 - a. **Subsidiariamente**, requer-se o deferimento de depósito judicial no valor de R\$ 121.207,60 (*cento e vinte e um mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos*) - ou 4% sobre valor cedido conforme patrimônio líquido das empresas, como forma de garantir a suspensão da exigibilidade tributária;



2. A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009 e a intimação do representante do Ministério Público para que se manifeste nos termos do artigo 12 da Lei nº 12.016/2009;

No mérito;

3. O reconhecimento da revogação tácita pela não-recepção dos art. 10, 12 e 13 da Lei 10.011 de 2013, porquanto incompatível materialmente com a EC nº 132/2023 e seu novel inciso VI do art. 155, par. 1o, de modo a reforçar a concessão da segurança final desse presente *mandamus*;
4. O reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ITCMD no Estado do Espírito Santo no caso concreto (conforme art. 150, CF), até que haja edição de nova legislação estadual em conformidade com a Emenda Constitucional nº 132/2023;
5. A concessão da segurança, confirmando-se a medida liminar, para impedir de forma definitiva a exigência do ITCMD na ausência de legislação válida no Estado do Espírito Santo.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000 (*mil reais*) para efeitos fiscais.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Vitória, 11 de Julho de 2025.

LUCAS PIMENTA JUDICE
OAB/ES 14.477



ROL DE DOCUMENTOS

1. **Procuração de Documentos Pessoais**
2. **Declarações de ITCMD na SEFAZ/ES:** *a que se busca suspensão de exigibilidade*
3. **Lei 10.011/2013:** Lei Estadual que institui o ITCMD, da qual os artigos 10, 12 e 13 foram revogados do ordenamento jurídico.
4. **Portal da Transparência:** comprovação de que o Estado do Espírito Santo não suspendeu as cobranças de ITCMD, mesmo diante da patente inexistência de legislação vigente que a autorize (corroborar o caráter da preventividade desse *writ*)

